

1001223-40.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Gilsa Elena Rios

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 15ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... - Acusado do cometimento de associação e tráfico de drogas, com posterior absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do CPP) - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Desprovemento de rigor - Responsabilidade Civil - Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

15ª Vara da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1001223-40.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001223-40.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adailton dos Santos Campos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilsa Elena Rios

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por ADAILTON DOS SANTOS CAMPOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Narra, em síntese, que responde a oito processo criminais, com relação aos quais foi absolvido por falta de provas em seis. Aduz que os outros dois feitos estão com audiência designada. Alega que foi preso indevidamente no curso da instrução criminal dos processo penais em comento, pelo que pugna pela condenação do Estado de São Paulo em danos morais, no valor de R\$ 484.800,00 e dano material.

Citada a FESP apresentou contestação de fls. 199/213. Alega ausência de responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de nexo de causalidade. Afirma que não houve prisão ilegal, pois as decisões judiciais que determinaram a prisão foram fundamentadas. Afirma que em nenhum dos feitos houve relaxamento de prisão ilegal, mas mera revogação de preventiva ou concessão de liberdade provisória, ante a cessação das circunstâncias que embasavam sua manutenção. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, a posterior absolvição, principalmente quando fundada em insuficiência probatória, não implica erro judiciário capaz de ensejar reparação. Impugna o valor postulado a título de indenização por dano moral. Ao final requer a improcedência.

Réplica nas fls. 221/228. AS partes não postularam produção de prova.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As questões de mérito a serem apreciadas são exclusivamente de direito, tornando desnecessária a produção de provas em audiência, razão pela qual promovo o julgamento antecipado integral do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

A presente demanda circunscreve-se à análise, em resumo, da manutenção do autor em prisão preventiva durante três meses em razão de oito processos criminais ajuizados em seu desfavor, dos quais obteve a absolvição em sete.

Sob o enfoque jurídico, a responsabilidade civil do estado sempre foi objeto de grande discussão.

Em esboço histórico, num primeiro momento tinha-se a ideia de que ao estado não era imputada qualquer responsabilidade por atos praticados pelos seus agentes, o que se traduzia na frase francesa *le roi le peut mal faire* (o rei não pode fazer mal).

Em seguida, à responsabilidade estatal foi trazido o conceito de culpa, transferindo a necessidade de prova pelo prejudicado da prática, por parte do estado, de atos de gestão – atos praticados pelo estado sob o regime jurídico privado e sobre os quais o estado teria responsabilidade – ou de atos de império – cujo regime jurídico era o de direito público e, como o estado não errava, seria portanto por eles irresponsável. Em progressão, a culpa administrativa aparece, revelando que bastaria a prova pelo prejudicado da falta do serviço público para a caracterização da responsabilidade, demonstrando que o serviço não foi prestado, que o foi de forma insuficiente ou que foi prestado com atraso, situações nas quais estaria presumida a culpa estatal, surgindo a obrigação em indenizar. Sem abandonar esse conceito, surge também a responsabilidade pelo risco administrativo, em que o elemento subjetivo desaparece (dolo ou culpa), o que faz surgir, assim, a denominada responsabilização objetiva.

O direito brasileiro, majoritariamente, aplica aos casos de omissão estatal a teoria da culpa administrativa, e nos casos de comissão, a teoria do risco administrativo, o que se extrai do artigo 37, parágrafo 6.º da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim prevê:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conclui-se, assim, pela aplicação da teoria do risco administrativo ao caso concreto tratado neste processo, o que estabelece a necessidade de prova, por parte do autor, além da conduta perpetrada, do nexo de causalidade e do dano efetivamente causado, orbitais a partir dos quais o deslinde do feito seguirá a sua conclusão. Como regra, é entendimento jurisprudencial dominante aquele segundo o qual, dadas as condições processuais enfrentadas pelos agentes públicos ao tempo da persecução penal, a prisão cautelar ou a submissão do réu ao processo criminal não conferem direito à indenização por abalo moral, eis que caracterizado o exercício do cumprimento de dever legal por parte dos atores da justiça criminal.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais embasada em prisão em flagrante, supostamente ilegal. Inquérito policial posteriormente arquivado, por falta de provas. Fato que não induz reparação, diante da ausência de abuso de poder ou de quaisquer outras ilegalidades – Circunstâncias verificadas na ocasião que mereciam elucidação e autorizavam a voz de prisão – Estrito cumprimento do dever legal. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004650-41.2021.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro:

29/03/2022);

Apelação Cível – Indenização por danos morais – Policial civil preso cautelarmente - Acusado do cometimento de associação e tráfico de drogas, com posterior absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do CPP) - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovemento de rigor – Responsabilidade Civil - Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a responsabilização – Ausência de ilicitude na conduta das autoridades - Exercício regular de direito, ante os elementos de que dispunham para a iniciativa - Irrelevância do desfecho da ação penal – Precedentes - Carência de prova suficiente de danos que mereçam indenização - Não vinga a pretensão reparatoria - Improcedência que se impunha - Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de Justiça concedida ao autor - R. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015424-47.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022);

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS – Pretensão à reparação civil por suposto erro judiciário – Impossibilidade – Autor preso provisoriamente com ulterior sentença de rejeição da denúncia – Atuação estatal consubstanciada em estrito cumprimento do dever legal – Responsabilização do Estado por erro judiciário que exige a existência de ilegalidade ou abuso na persecução criminal por parte dos agentes públicos – Não configuração no caso concreto – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1049495-02.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Entretanto, na hipótese dos autos, reputo evidenciado o abuso no exercício da persecutio criminis por parte dos agentes públicos competentes, o que se configura como ilegalidade que, ante o cenário fático apresentado, impõe a responsabilização do requerido.

A exposição fática da inicial veio acompanhada de documentos que comprovam a via crucis percorrida pelo autor.

Com efeito, o autor foi absolvido nos processos criminais nºs 1521770-58.2019.8.26.0050, 1521781-87.2019.8.26.0050, 1522193-18.2019.8.26.0050, 1522198-40.2019.8.26.0050, 1522196-70.2019.8.26.0050, 1527703-12.2019.8.26.0050 (fls. 24/154), o que já deixa entrever a ilegalidade dos atos estatais em desfavor do autor.

O autor mantém ocupação lícita, conforme Contrato de fls. 169/172.

Verifica-se, ainda, que as datas em que imputadas as condutas criminosas constam dos pontos de frequência juntados às fls. 176/186, fundamentos que compuseram grande parte das absolvições.

A MM. Magistrada sentenciante do Processo nº 1522196-70.2019.8.26.0050, assim se manifestou quanto ao critério de escolha de fotografias do réu no âmbito policial:

Diante disso, tem-se que, embora como regra a indenização nos casos de prisão cautelar posterior à qual sobrevenha absolvição não ensejem direito à indenização, no caso dos presentes autos o agir estatal agiu com exagero contra pessoa que, até o presente momento foi absolvida de inúmeros processos criminais.

Digno de nota, é a cor de pele do autor (fl. 16), fator importante no cenário nacional no que diz respeito ao reconhecimento de pessoas, circunstância também apontada naquele processo criminal por meio de decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, que peço vênha para transcrever:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). (...)

VI. O reconhecimento de pessoas e a seletividade do sistema penal

Relatório apresentado recentemente, em setembro de 2020, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou que 53 pessoas foram acusadas com base em reconhecimento fotográfico falho ao longo dos últimos seis anos. Os casos têm em comum o fato de o(a) acusado(a) haver sido reconhecido(a) por meio fotográfico na fase inquisitiva (Disponível em:

<http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/imagens/d12a8206c9044a3e92716341a99b2f6f.pdf> f. Acesso em: set. 2020).

A análise, que levou em conta as 19 varas criminais do Estado do Rio de Janeiro e envolveu os casos recebidos entre 1º/6/2019 e 10/3/2020, evidenciou falhas de procedimento da polícia na hora de se utilizar do reconhecimento fotográfico. Todos os indivíduos foram processados por roubo, na forma simples ou com causa de aumento

(em sua maioria, pelo concurso de pessoas ou pelo emprego de arma), à exceção de um deles, acusado de homicídio.

Com relação à prisão preventiva, o relatório apontou que, em 86,2% dos casos, houve a decretação da cautela extrema. Quanto à cor da pele, apenas 20% dos indivíduos eram brancos (consta do referido relatório que a informação sobre a cor da pele foi retirada dos registros policiais), o que sugere algo até intuitivo, o racismo estrutural. (...) (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Formado este cenário, é de se reconhecer o dano moral perpetrado.

Neste aspecto, é sabido que o dano moral só se configura quando violado, em última análise, direitos da personalidade. Ao contrário do que possa parecer, segundo o E. Superior Tribunal de Justiça, a dor, o vexame, o sofrimento e a humilhação podem ser consequências do dano moral, mas não a sua causa, fato que implica concluir a desnecessidade desses fatores para a ocorrência do dano moral indenizável (STF, 4ª Turma, REsp 1.245-550-MG, Rel Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/03/2015, Informativo 559).

Definida a responsabilização, passa-se à análise do quantum indenizatório.

Segundo definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, à aferição do dano moral aplica-se o critério bifásico, (i) cotejando grupo de casos e (ii) realizando-se o ajuste às circunstâncias do caso. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. 1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa. 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EResp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014). 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016).

À vista de casos análogos, e considerando o tempo em que restou preso o autor, bem como quanto à demora para o deslinde do processo-crime, afigura-se razoável a

fixação em R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Quanto aos danos materiais, o autor junta o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (fls. 174/175), do qual se extrai que teve o gasto de R\$ 9.000,00, valor que reputo fixado como dano material.

Por fim, quanto ao índice de juros e correção monetária aplicáveis, convém mencionar o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021 que, em seu artigo 3º assim estabeleceu:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial a fim de condenar a requerida:

a) ao pagamento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais sofridos pelo autor, devendo incidir juros e correção monetária de acordo com a SELIC e nos termos da EC nº 113/21, a partir do arbitramento (Súmula 312 do C. Superior Tribunal de Justiça);

B) ao pagamento de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) pelos danos materiais comprovadamente sofridos pelo autor, devendo incidir juros e correção monetária de acordo com a SELIC e nos termos da EC nº 113/21, a partir da data da prisão (05/09/2020).

Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

P. I. C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

GILSA ELENA RIOS

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.